

1500842-20.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... requerido (autos n.º 0000171-81.2015.8.26.0599 - roubo - pena julgada extinta em 26/11/2019; autos n.º 0001570-41.2014.8.26.0451 - furto qualificado tentado - pena extinta 11/10/2019; autos n.º 0019025-87.2012.8.26.0451 - roubo tentado - pena extinta em 11/10/2019).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição e apreensão de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 05/07, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3433-4177, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital n.º:

1500842-20.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2144946/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 18182027 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 1456/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2144946 - 02º D.P. PIRACICABA, 1456/21/922 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DOMINGUES SOUZA

Vítima:

KELLY CRISTIANE DE OLIVEIRA

Artigo da Denúncia:

*

Aos 25 dias do mês de janeiro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Paulo Kishi e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentados as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Ângelo José de Carvalho Neto e Jamisson Ferreira da Silva.

Ausente o acusado Leandro Domingues Souza, o qual foi intimado para comparecer ao fórum local e não o fez e, tentado contato através do telefone por ele indicado, não obtivemos êxito.

Ausente também a vítima Kelly Cristiane de Oliveira, a qual, ao ser intimada, informou que tinha condições de participar virtualmente da audiência, mas não o

fez. Tentado contato via telefone, também não obtivemos êxito. Outrossim, foi enviada mensagem no whats app da vítima, com o link para a audiência, e o todo procedimento instrutorio para que a mesma ingressasse na audiência. Ela visualizou a mensagem, mas não respondeu e não ingressou na reunião. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Ângelo e Jamisson) pelo sistema virtual.

Pelas partes foi dito que desistem da oitiva da vítima.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Tendo em vista que o acusado foi devidamente intimado e não compareceu ao forum local para ser ouvido e nem ingressou virtualmente na reunião, DECRETO A SUA REVELIA.

Homologo a desistência das partes em relação à vítima Kelly Cristiane de Oliveira. "Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza, LEANDRO DOMINGUES SOUZA está sendo processado como incurso no artigo 155, §1º e 4º, II, do Código Penal.

Feito regularmente processado.

Procede a ação penal.

DOS FATOS

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de maio de 2021, por volta de 22h40min, na Rua Ubatuba, n.º 348, Bairro Jaraguá, nessa cidade e Comarca de Piracicaba/SP, LEANDRO DOMINGUES SOUZA, qualificado e indiciado às fls. 06/07 e 27/31, durante o período de repouso noturno, subtraiu, para si ou para outrem, mediante escalada (laudo a ser oportunamente juntado a fls. 204/209), 01 (um) reator de lâmpada fluorescente, avaliado em R\$5,00 (cinco reais), 01 (uma) bomba calibradora de pneus, avaliada em R\$10,00 (dez reais), e 01 (uma) tampa de filtro de motor automotivo, avaliada em R\$50,00 (cinquenta reais) (auto de avaliação fls. 16), pertencentes à moradora "Silvia", representada por Kelly Cristiane de Oliveira.

Segundo apurado, aproveitando-se da vigilância atenuada pelo período de repouso noturno, LEANDRO - que de longa data se dedica à prática de delitos patrimoniais - se dirigiu ao imóvel para a prática de furto. Após escalar o portão, ingressou no imóvel e subtraiu os objetos acima descritos. Ao ser interpelado por moradores, fugiu pelo telhado das residências vizinhas (fls. 04).1 Cf. item 2 da cota ministerial.

Momentos depois, foi detido por policiais militares acionados ao local: os materiais foram recuperados em sua posse (fls. 02/03).

Informalmente, LEANDRO confessou a prática delitiva (fls.02/03). Na Delegacia de Polícia quedou-se silente (fls. 06/07).

Os objetos recuperados foram restituídos ao representante (autos fls. 13/14 e 15/18).

Diante das circunstâncias, em especial a condição pessoal, a comunicação aos policiais militares, a tentativa de fuga e a recuperação da res furtiva em sua posse, é certa a responsabilidade do denunciado pelo crime de furto.

DA PROVA NA FASE JUDICIAL

Kelly Cristiane de Oliveira - representante - fls. 05.1 - Ângelo José de Carvalho Neto - Policial Militar - fls. 02;2 - Jamisson Ferreira da Silva - Policial Militar - fls. 03.

Em juízo o policial Angelo disse que foram solicitados pelo 190 de furto em andamento. O indivíduo foi visto em cima do telhado. Feito o cerco o réu foi preso. Com ele foi apreendida uma mochila com objetos e ele confessou que havia subtraído na rua Ubatuba. Ele disse que havia escalado o muro e rompeu fiação da cerca elétrica . A solicitação ocorreu por volta de 22:40 hs. Não conhecia os réus.

O policial Jamisson disse que foram acionados pelo Copom sobre furto em andamento. No local havia várias pessoas na rua informando que o indivíduo estava em cima do telhado. Feito o cerco o réu foi detido. Com ele havia uma sacola com os objetos

subtraídos e ferramentas utilizadas na subtração.

Assim, diante da prisão em flagrante em poder da res furtiva e ferramentas, confissão na fase policial e revelia em juízo, a prova colhida é suficiente ao desate condenatório.

DA PENA

Providenciadas nos autos a FA e respectivas certidões (fls. 72/115): LEANDRO DOMINGUES SOUZA ostenta maus antecedentes – condenado por roubo nos autos n.º 0000171-81.2015.8.26.0599 (pena extinta em 26.11.2019 – fls. 74), e é reincidente – condenado por furto nos autos n.º 0013187-76.2006.8.26.0451 (trânsito em julgado em 14.09.2009 – fls. 76/77), 0021675-20.2006.8.26.0451 (trânsito em julgado em 20.04.2012 – fls. 79), 0025754-76.2005.8.26.0451 (trânsito em julgado em 31.07.2006 – fls. 79/80), e 0027176-23.2004.8.26.0451 (trânsito em julgado em 23.03.2009 – fls. 80), por tentativa de furto nos autos n.º 0001570-41.2014.8.26.0451 (pena extinta 11.10.2019 – fls. 74/75) e 0012627-64.2009.8.26.0602 (trânsito em julgado em 05.09.2012 – fls. 82/83), por tentativa de roubo nos autos n.º 0019025-87.2012.8.26.0451 (pena extinta em 11.10.2019 – fls. 77), e atualmente é processado por furto qualificado nos autos n.º 1500062-80.2021.8.26.0599, fato praticado em 08.01.2021, e se encontrava em liberdade provisória desde 28 de janeiro de 2021. Regime inicial fechado. Não se aplica a súmula 269 do STJ.

Não cabe substituição por restritiva de direitos.

DO PEDIDO FINAL

Pela procedência da presente ação nos termos da inicial.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juiza, Leandro Domingues Souza foi denunciado como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, II, do Código Penal.

Segundo a denúncia (fls. 152-153), no dia 27 de maio de 2021, por volta de 22h40, na Rua Ubatuba, n.º 348, bairro Jaraguá, nessa cidade e comarca de Piracicaba/SP, Leandro, durante o período de repouso noturno, subtraiu, para si ou para outrem, mediante escalada, 01 (um) reator de lâmpada fluorescente, avaliado em R\$5,00 (cinco reais), 01 (uma) bomba calibradora de pneus, avaliada em R\$10,00 (dez reais), e 01 (uma) tampa de filtro de motor automotivo, avaliada em R\$50,00 (cinquenta reais) (auto de avaliação fls. 16), pertencentes à moradora "Silvia", representada por Kelly Cristiane de Oliveira.

Ainda de acordo com a inicial, aproveitando-se da vigilância atenuada pelo período de repouso noturno, Leandro se dirigiu ao imóvel para a prática de furto. Após escalar o portão, ingressou no imóvel e subtraiu os objetos acima descritos. Ao ser interpelado por moradores, fugiu pelo telhado das residências vizinhas (fls. 04). Momentos depois, foi detido por policiais militares acionados ao local: os materiais foram recuperados em sua posse.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o réu exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (fls. 6-7).

Em solo policial, Kelly Cristiane de Oliveira, vítima, afirmou que: "está cuidando da casa localizada na rua Ubatuba, número 348, para Silvia, a qual é sua amiga e está doente. Fica com a chave do local, mas não sabe maiores dados sobre a vítima.

Na noite dos fatos, ouviu o indiciado pulando de casa em casa na vizinhança. Os policiais detiveram o implicado numa das casas da região. Quando de sua detenção, o indiciado estava com alguns objetos, em relação às quais reconhece como pertencentes à casa de Silvia. Não viu a subtração propriamente dita, mas sabe que os objetos encontrados na posse do indiciado foram subtraídos do local" (fls. 5).

Ângelo José de Carvalho Neto, policial militar, contou que: "foi acionado via COPOM para atender ocorrência versando sobre um indivíduo que estaria andando sobre o telhado de várias residências. O solicitante, identificado como Lúcio, não presente no plantão, informou que havia um indivíduo em cima de sua casa, no telhado.

Chegando no local constatou que o indivíduo em tela, ora indiciado, estava acessando o telhado de várias residências. Acionou apoio de outras viaturas e realizou o cerco, conseguindo detê-lo na residência localizada na rua Baronesa de Resende, número 184. Na posse do investigado havia vários objetos, em relação aos quais foi constatado terem sido furtados da residência localizada na rua Ubatuba,

número 348, a qual está sob responsabilidade de Kelly. De maneira informal, o implicado disse que subtraiu os objetos de uma residência vazia, pulando o portão, sendo que fugiu pelo telhado das casas em razão da população ter lhe flagrado e lhe agredido" (fls. 2).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo policial militar Jamisson Ferreira da Silva (fls. 3).

As fls. 74-83, certidão de objeto e pé que indica os maus antecedentes (autos n.º 0025754-76.2005.8.26.0451 - furto qualificado - trânsito em julgado em 31/7/2006; autos n.º 0021675-20.2006.8.26.0451 - furto qualificado - trânsito em julgado em 20/4/2012; autos n.º 0027176-23.2004.8.26.0451 - furto qualificado tentado - trânsito em julgado em 23/3/2009; autos n.º 0012627-64.2009.8.26.0602 - furto tentado - trânsito em julgado em 5/9/2012) e a reincidência do requerido (autos n.º 0000171-81.2015.8.26.0599 - roubo - pena julgada extinta em 26/11/2019; autos n.º 0001570-41.2014.8.26.0451 - furto qualificado tentado - pena extinta 11/10/2019; autos n.º 0019025-87.2012.8.26.0451 - roubo tentado - pena extinta em 11/10/2019).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13-14, auto de reconhecimento do objeto de fls. 15, auto de avaliação de fls. 16, fotografia de fls. 17, auto de entrega de fls. 18.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Inicialmente, foi ouvido Ângelo José de Carvalho Neto, policial militar. Trouxe aos autos as mesmas informações que prestou na delegacia: foram acionados via COPOM, foram ao local, os populares estavam agitados e apontavam para o telhado, onde Leandro estava. Abordaram Leandro em cima do telhado e tentando fugir. Ele disse que estava com medo da população, que iam agredi-lo, e não da polícia. Por isso, quando os policiais pediram para que descesse ao quintal onde os esperavam, ele desceu. Ele tinha uma mochila com alicate, um reator de lâmpada e uma tampa de filtro de Fusca. O réu indicou a residência de onde subtraiu os objetos. A responsável pela casa de onde os objetos foram subtraídos disse que estavam no quintal. Disse que o réu escalou o portão no local do furto e danificou uma cerca elétrica na fuga. Disse que quando chegou ao local, ele estava fugindo sobre o telhado de outras casas, mas que não viu o réu escalando o muro da casa furtada. Sobre o horário dos fatos, disse que foi acionado por volta de 22h40.

b) Ouvido Jamisson Ferreira da Silva, policial militar. Além do que contou o seu colega de farda, relatou que a casa furtada estava vazia, mas uma vizinha tinha a chave e franqueou a entrada dos policiais. A porta da casa estava aberta, não sabe se o réu rompeu ou se estava aberta antes. Ao ser abordado, o réu disse que era usuário de drogas e que havia furtado para sustentar o vício. Ele disse também que entrou na casa pulando o portão. Perguntado sobre as características desse portão, disse que não era alto, mais ou menos 1,70m.

c) O réu é revel.

- DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA

Tendo em vista que nada foi subtraído e o valor dos bens é de R\$65,00, o caso é de absolvição por atipicidade material da conduta, em virtude do reconhecimento do princípio da insignificância.

Nesse contexto, de início, saliente-se que insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade, como afirma, a propósito, Paulo Queiroz:

"O princípio da insignificância constitui, portanto, um instrumento por cujo meio o juiz, em razão da manifesta desproporção entre crime e castigo, reconhece o caráter não criminoso de um fato que, embora formalmente típico, não constitui uma lesão digna de proteção penal, por não traduzir uma violação realmente importante ao bem jurídico tutelado" (Direito penal: parte geral, v. 1. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 91).

Dinamizando a incidência da insignificância, o Supremo Tribunal Federal, fixou o entendimento sobre a necessidade da verificação de quatro pressupostos para sua aplicação: a) a pequena ofensividade da conduta do agente; b) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; c) nenhuma periculosidade social da ação; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada:

"E M E N T A: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGÍTIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR DE R\$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social." (HC 84412, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. em 19/10/2004).

Este julgado tornou-se o verdadeiro leading case da matéria e vem sendo reiterado por inúmeras decisões, tanto do próprio Supremo Tribunal Federal, quanto deste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a título exemplificativo, citam-se os seguintes precedentes: a) no STF: HC 97129/RS, Min. Rel. Eros Grau; HC 97189/RS, Min. Rel. Ellen Gracie; STF, HC 96496/MT, Min. Rel. Eros Grau; HC 105974, Min. Rel. Ayres Britto; HC 93393, Min. Rel. César Peluso; HC 93453, Min. Rel. Joaquim Barbosa; b) no STJ, RHC 23.376/MG, Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho; HC 198996/SC, Min. Rel. OG Fernandes; HC 34626/MG, Min. Rel. Félix Fischer; STJ, HC 18314/RJ; HC 139015/SP, Min. Rel. OG Fernandes; HC 122435/MG, Min. Rel. Celso Limongi.

Ora, a aplicação do princípio da insignificância é uma questão de política criminal, afastando a intervenção penal para delitos que, do ponto de vista jurídico-penal, são considerados menos reprováveis. E, ao fazê-lo, permite-se que o poder punitivo seja exercido de forma mais enérgica em relação aos delitos que, efetivamente, atentam contra a paz social.

Saliente-se, ainda, que o reconhecimento da insignificância não irá causar qualquer desamparo à vítima. Pelo contrário, o que se postula é que seja reconhecida a insignificância do ponto de vista jurídico-penal. Ou seja, o que se requer é o afastamento das consequências jurídico-penais. Com isso, a vítima, caso entenda que tenha sofrido algum tipo de prejuízo, ainda poderá pleitear a devida reparação na esfera civil, eis que a sentença que reconhece a atipicidade da conduta não produz coisa julgada na esfera extrapenal (CPP, art. 67, III). Percebe-se, dessa forma, que somente se justificaria manter a persecução penal para assegurar à vítima um título executivo judicial, eis que a sentença penal condenatória torna certa a obrigação de indenizar (CP, art. 91 c. c/ CPC, art. 515, VI). Todavia, é necessário separar as esferas penal e civil e, assim, retiradas as consequências jurídico-penais da conduta, não se justifica a manutenção do processo penal, seja por causa dos inúmeros gravames que serão causados ao imputado, seja pelo fato que os interesses da vítima - meramente econômicos - ainda estarão amparados pelo

ordenamento.

Se é assim, impõe-se a absolvição, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

- DA FIXAÇÃO DA PENA

Subsidiariamente, na remota possibilidade de condenação, passa-se a discorrer sobre a pena.

a) Do afastamento da qualificadora do art. 155, § 4º, II, CP

Ressalta-se que a prática do furto qualificado pela escalada pressupõe a superação de algo utilizado para a proteção da coisa. Nesse sentido, leciona Rogério Greco, ao apontar que, “[...] em sede doutrinária, considera-se obstáculo tudo aquilo que tenha a finalidade precípua de proteger a coisa e que também não seja a ela inerente” (GRECO, Rogério. Código Penal: comentado. 5. ed. Niterói: Impetus, 2011, p. 417).

Não é diferente o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao apontar que “É imprescindível, para a constatação da qualificadora referente à escalada no crime de furto, a realização do exame de corpo de delito, o qual pode ser suprido pela prova testemunhal ou outro meio indireto somente quando os vestígios tenham desaparecido por completo ou o lugar se tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos, o que não foi evidenciado nos autos (HC 456.927/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019).

Trata-se, pois, de figura qualificada que deixa vestígios e, por isso é imprescindível a realização de um laudo que comprove a escalada (CPP, art. 158).

Entretanto, o laudo de fls. 204-209 não concluiu que houve a escalada, apenas afirmou que: “o furto se deu, segundo consta, mediante escalada do portão do imóvel n.º 348 da rua Ubatuba, dando acesso aos telhados das casas, com posterior rompimento da cerca elétrica do imóvel n.º 184 da rua Baroneza de Resende”.

Ademais, a acusação não trouxe aos autos qualquer prova testemunhal que indique as características do imóvel furtado, se o portão ou o muro são altos ou baixos, ou como se deu o ingresso no local. Somente se sabe que o indivíduo tentou se esconder da população no telhado de outras casas, mas não se sabe como a dinâmica se deu na casa furtada. O policial Jamisson, aliás, relatou que o portão não era alto, não demandando destreza para acessar o local.

Portanto, não ficou demonstrada a configuração da qualificadora prevista pelo art. 155, § 4º, II, do Código Penal.

b) Da pena-base

De rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal, pois não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No mais, as condenações anteriores devem ser avaliadas na segunda fase de fixação de pena, sob pena de bis in idem.

c) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, a reincidência que deverá ser compensada com a confissão, ainda que seja apenas a informal.

d) Do repouso noturno

Na terceira etapa de dosimetria de pena, é de rigor o afastamento da majorante do repouso noturno. Isso porque, conforme se infere da redação do § 1º do art. 155 do Código Penal, é imprescindível a perturbação do repouso noturno, o que não se pode considerar ter ocorrido, tendo em vista que o réu foi facilmente avistado pelos populares vizinhos e denunciado. Tivesse mesmo o réu se aproveitado da tranquilidade do repouso noturno, não teria sido flagrado tão facilmente pelos vizinhos.

Sendo assim, requer seja afastada a majorante, eis que não ocorreu a “perturbação do repouso noturno”.

- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, conforme disposto nas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, assim como a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, no art. 33, § 3º, do Código Penal, não se pode apelar à gravidade em abstrato do delito para justificar a imposição de regime mais gravoso para o caso.

- DO RECURSO EM LIBERDADE

Por fim, considerando que o requerido respondeu ao presente processo em liberdade,

não praticou crime com violência ou grave ameaça e não representa perigo à segurança da sociedade, requer-se que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

LEANDRO DOMINGUES SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 27 de maio de 2021, por volta de 22h40, na Rua Ubatuba, n.º 348, Bairro Jaraguá, nessa cidade e Comarca de Piracicaba/SP, durante o período de repouso noturno, subtraiu, para si ou para outrem, mediante escalada, 01 (um) reator de lâmpada fluorescente, avaliado em R\$5,00 (cinco reais), 01 (uma) bomba calibradora de pneus, avaliada em R\$10,00 (dez reais), e 01 (uma) tampa de filtro de motor automotivo, avaliada em R\$50,00 (cinquenta reais) (auto de avaliação fls. 16), pertencentes à moradora "S.", representada por K. C. O..

Segundo a denúncia, aproveitando-se da vigilância atenuada pelo período de repouso noturno, Leandro – que de longa data se dedica à prática de delitos patrimoniais – se dirigiu ao imóvel para a prática de furto.

Após escalar o portão, ingressou no imóvel e subtraiu os objetos acima descritos. Ao ser interpelado por moradores, fugiu pelo telhado das residências vizinhas (fls. 04).

Momentos depois, foi detido por policiais militares acionados ao local: os materiais foram recuperados em sua posse (fls. 02/03).

Informalmente, Leandro confessou a prática delitiva (fls. 02/03). Na Delegacia de Polícia quedou-se silente (fls. 06/07).

Os objetos recuperados foram restituídos ao representante (autos fls. 13/14 e 15/18).

Diante das circunstâncias, em especial a condição pessoal, a comunicação aos policiais militares, a tentativa de fuga e a recuperação da res furtiva em sua posse, é certa a responsabilidade do réu pelo crime de furto.

A denúncia foi recebida (fls. 154/155), o réu citado (fls. 162), apresentando resposta escrita, na qual optou por manifestar sobre o mérito posteriormente, bem como requereu a revogação da prisão preventiva (fls. 166/169).

Ao réu foi concedido o benefício da liberdade provisória, o recebimento da denúncia foi mantido, designando-se audiência virtual (fls. 175/177).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas comuns, sendo decretada a revelia do réu.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, pelo auto de reconhecimento de objeto de fls. 15, pelo auto de avaliação de fls. 16, que avaliou os bens em R\$65,00, pela fotografia dos objetos de fls. 17 e pelo auto de entrega de fls. 18.

2) Da autoria

A autoria criminosa é certa e deve ser atribuída ao réu.

Durante a fase policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 06).

Em Juízo, o réu deixou de comparecer à audiência, mesmo intimado, sendo decretada sua revelia.

A negativa de autoria restou isolada nos autos, diante do conjunto probatório produzido nos autos. Vejamos.

Ouvida apenas em sede policial, a representante da vítima K.C.O. declarou que está cuidando da casa localizada na Rua Ubatuba, número 348, para S., a qual é sua amiga e está doente. Fica com a chave do local, mas não sabe maiores dados sobre a vítima. Na noite dos fatos, ouviu o réu pulando de casa em casa na vizinhança. Os policiais detiveram o réu numa das casas da região. Quando de sua detenção, o réu

estava com alguns objetos, os quais reconhece como pertencentes à casa de S. Não viu a subtração propriamente dita, mas sabe que os objetos encontrados na posse do réu foram subtraídos do local (fls. 05).

O policial militar Ângelo José de Carvalho Neto relatou que estava de serviço, quando foram solicitados para atender ocorrência de possível furto em andamento. A solicitação partiu do 190 e a solicitante disse ter visto pessoa correndo sobre seu telhado. Quando chegaram ao local, a população estava bem nervosa, dizendo que uma pessoa estava passando por cima de várias residências. Conseguiram encontrar o réu em cima de um telhado. O proprietário da residência já tinha aberto a casa e ingressaram para conseguir deter o réu. Conseguiram encontrar o réu andando sobre o telhado e pediram que ele descesse, sendo obedecidos. O réu falou que estava fugindo, porque estava com medo da população. Ele foi abordado, com uma mochila. Nessa mochila, havia objetos como alicate, reator de lâmpada e tampa de filtro de Fusca, que ele disse terem sido subtraídos em determinada residência. Foram até a residência e o réu disse que tinha pulado o portão. Conseguiram fazer contato com a responsável e ela confirmou a subtração. O capô do Fusca estava aberto. Os objetos subtraídos estavam no quintal da casa. Não conhecia o réu. O réu danificou fios da cerca elétrica de onde ele foi detido. O horário da abordagem foi às 22h50. Quando foram solicitados, o solicitante disse que o réu corria nos telhados.

O também policial militar Jamisson Ferreira da Silva narrou que estavam em patrulhamento, quando foram acionados via Copom, para atendimento de possível furto em andamento. Quando chegaram ao local, havia várias pessoas na rua, a maioria informando que o réu estava em cima do telhado. Fizeram o cerco com outras viaturas e uma solicitante informou que ele estava ao lado da casa que tinha acabado de furtar. Entraram nessa casa autorizados pelo vizinho e conseguiram encontrar o réu, em cima de um muro. Conseguiram fazer o réu descer. Com ele, havia os objetos furtados. Os populares informaram que ele tinha entrado numa casa, onde não havia ninguém. Uma das vizinha, contudo, tinha a chave, porque cuidava do imóvel para a proprietária. Entraram na casa e viram que ele tinha pegado um reator de lâmpada fluorescente e uma tampa de filtro de um fusca. Dentro da mochila do réu tinha alicate, faca, chave. Inclusive, tinha um Fusca na residência, de onde a tampa tinha sido retirada. O réu falou que era usuário de drogas e confessou que estava praticando furto, por esse motivo. O réu disse que tinha pulado o portão, para entrar na casa da vítima. Não conhecia o réu. o portão era fechado e tinha lanças. Ele tinha cerca de 1,70m.

Com efeito, a prova é suficiente para a certeza da autoria.

O réu, na fase policial, permaneceu em silêncio. Judicialmente, deixou de fornecer sua versão, porque, mesmo intimado, não compareceu à audiência.

A representante da vítima não presenciou os fatos, mas ouviu o réu pulando o telhado das casas na vizinhança. Narrou que o réu foi detido pelos policiais na posse de alguns objetos que reconheceu como pertencentes à casa da vítima.

Os policiais contaram que foram acionados para atender ocorrência versando sobre um indivíduo que estaria caminhando sobre o telhado de várias residências. No local, conseguiram detê-lo na posse de vários objetos, constatando que pertenciam à residência da vítima. Informalmente, o réu confessou a subtração.

Nesse sentido, o réu foi visto no telhado de várias residências e preso na posse dos objetos subtraídos do interior da casa da vítima.

Assim, ter o réu sido detido na posse da res, por si só, já faz presumir-se a autoria, cabendo ao próprio acusado a tarefa de afastar tal presunção.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples - Recurso defensivo - Absolvição - Fragilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Apreensão da res em poder do acusado gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova - Pena reclusiva mantida - Dia-multa fixado no valor unitário mínimo legal - Regime inalterado dada a comprovada presença de antecedentes criminais - Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Ausência de recurso ministerial nesse sentido - Recurso parcialmente provido". (TJSP - Apelação Criminal 0000318-78.2015.8.26.0544. Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Fernando Torres Garcia - j. 20/08/2020 - grifei)

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo concurso de agentes - Sentença condenatória - Pleito absolutório inadmissível - Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva - Réu que foi surpreendido na posse do produto furtado, sem explicação plausível - Prova oral suficiente para a condenação - (...)". (TJSP - Apelação Criminal 1500587-42.2018.8.26.0575. Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto - j. 02/03/2021 - grifei)

"APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO - ARTIGO 155, § 1º e § 4º, inciso I, DO CÓDIGO PENAL - Subtração de diversos itens de vestuário do interior de estabelecimento comercial, mediante quebra da vidraça da loja, durante repouso noturno - Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva. Confissão. Apreensão em flagrância em posse da res. Ainda, palavras da vítima e dos servidores policiais seguras e consistentes. Condenação mantida - (...). RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP - Apelação Criminal 1501430-28.2019.8.26.0201. Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas - j. 28/02/2021 - grifei)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA E VIOLÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. "RES" NA POSSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES A CONVENCER DO DECRETO CONDENATÓRIO. CONSUMAÇÃO. A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA É O BASTANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 59, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMPROVADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO RÉU. (...) 4. Encontro de parte da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedora, tanto mais ante o reconhecimento que a vítima realizou do indigitado agente. Inversão do ônus da prova. Precedentes do STF, "mutatis mutandis" (ARE 822.045/SC - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 28.08.2014 - DJE 02.09.2014 e RE 731.662/SC - Rel. Min. Dias Toffoli - j. 22.05.2014 - DJE - 28.05.2014) e do STJ (ARE 329.535/PI - Rel. Min. Marilza Maynard - 6ªT. - DJE 25.08.2014 e HC 243.033/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - 5ªT. - j. 19.11.13) e do TJSP (Ap. 0086071-98.2013.8.26.0050 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 17.09.2014; Ap. 0010663-73.2011.8.6.0664 - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - j. 02.09.2014 e Ap. 0090615-03.2011.8.26.0050 - Rel. Des. Grassi Neto - j. 20.03.2014). (...) (TJSP; Apelação Criminal 0038485-65.2013.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 07/12/2018).

APELAÇÃO DAS DEFESAS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E PELO CONCURSO DE AGENTES. VALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. "RES" ENCONTRADA EM PODER DOS RECORRENTES, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉUS CONFESSOS. TESTEMUNHOS DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. PRECEDENTES. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. "MUTATIO LIBELLI". FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REGIME ABERTO MANTIDO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. (...) 2. Materialidade e autorias comprovadas com relação ao crime de furto. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado às espécies, sobretudo pelas provas orais, colhidas perante o contraditório, recepcionadas pelas demais provas dos autos. 3. Furto. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedora. Precedentes do TJSP (Ap. 0000880-56.2011.8.26.0244 - 8ª C - Rel. Des. Alcides Malossi Junior - j. 23.02.2017 - DJe 23.02.2017; Ap. 0023445-74.2015.8.26.0405 - 3ª C - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - j. 14.02.2017 - DJe 14.02.2017; Ap. 0002534-30.2011.8.26.0357 - 8ª C - Rel. Des. Carlos Monnerat - j. 09.02.2017 - DJe 16.02.2017; Ap. 0002710-04.2014.8.26.0066 - 9ª C - Rel. Des. Souza Nery - j. 15.12.2016 - DJe 09.01.2017 e Ap. 3001436-92.2013.8.26.0484 - 8ª C - Rel. Des. Grassi Neto - j. 22.09.2016 - DJe 31.01.2017). (...) (TJSP; Apelação 0042098-25.2015.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do

Julgamento: 10/04/2018; Data de Registro: 13/04/2018).

APELAÇÕES. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. "RES" ENCONTRADA NA POSSE DOS RECORRENTES, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES. ATIPICIDADE MATERIAL EM DECORRÊNCIA DO PRÍNCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, §2º, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. REGIME ABERTO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. (...) 3. A apreensão das "rei" em poder dos acusados acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhes a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem. Precedentes do TJSP. (...) (TJSP - Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Jaú; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 03/02/2016; Data de registro: 04/02/2016).

"Agente encontrado na posse da res furtiva, sem explicação razoável para o fato, autoriza presunção de responsabilidade somente afastável mediante produção de prova consistente" (TACRIM - SP - AC - Rel. Renato Nalini - RT 719/458).

"Em sede de furto, a apreensão da res furtiva em poder do réu ou em circunstâncias que presumam estar ele envolvido com ela, representa idôneo liame entre a autoria e o evento" (TACRIM - SP - AC - Rel. Fernandes Oliveira - RJD 18/74).

"FURTO. Prova. Apreensão do bem em poder do réu. Ausência de comprovação satisfatória da suspeitosa posse. Suficiência. Condenação. Necessidade. - Em tema de furto, a apreensão do bem com o acusado é importante elementos de prova, máxime quando o sujeito não comprova satisfatoriamente a licitude da suspeitosa posse." (TJSP - Processo: APL 54461320118260191 SP 0005446- 13.2011.8.26.0191 - Relator(a): João Morengi - Julgamento: 24/10/2012 - Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal - Publicação: 01/11/2012).

"FURTO QUALIFICADO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade delitiva - Bem furtado apreendido em poder do réu - Provas que demonstram a responsabilidade penal do acusado - (...) Recurso improvido - (voto nº 12406)." (TJSP - Processo: APL 179275320058260050 SP 0017927- 53.2005.8.26.0050 - Relator(a): Newton Neves - Julgamento: 28/06/2011 - Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal - Publicação: 04/07/2011).

"APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - -Absolvição - Impossibilidade - Materialidade e autoria bem demonstradas. Réu preso em flagrante de posse da res furtiva. (...) APELO IMPROVIDO." (TJSP - Processo: APL 88180420108260482 SP 0008818-04.2010.8.26.0482 - Relator(a): Camilo Léllis - Julgamento: 26/07/2012 - Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito - Criminal Publicação: 06/08/2012).

"FURTO Crime consumado - Réu surpreendido na posse do bem furtado buscando escondê-lo ante a chegada da polícia. Negativa do réu não amparada pelos depoimentos seguros da vítima e testemunhas. (...) Regime prisional alterado para o semiaberto, pois ausente idônea fundamentação Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal - Recurso provido apenas para esse fim - (voto n. 16794)." (TJSP - Processo: APL 9000066822011826 SP 9000066-82.2011.8.26.0439 - Relator(a): Newton Neves - Julgamento: 13/11/2012 - Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal - Publicação: 14/11/2012).

No caso dos autos, o réu não se manifestou, inquisitivamente e em Juízo, de forma que a presunção se tornou certa.

Assim, não resta dúvidas sobre a autoria delitiva.

3) Do repouso noturno

O furto cometido durante o repouso noturno, assim reconhecido entre o período em que, naquela localidade onde os fatos ocorreram, a população costumeiramente se recolhe e desperta para a vida cotidiana, é apenado com maior rigor, uma vez que o bem jurídico tutelado está mais vulnerável.

No caso concreto, o réu adentrou à residência por volta das 22h40 e furtou os objetos. Assim, mesmo que não houvesse moradores na residência, o fato é que o horário era de menor atenção e a proteção da res estava diminuída, por isso, a causa de aumento deve ser reconhecida.

Sobre o assunto, assim já se manifestou Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 15ª edição, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2015, p. 876): "a causa de aumento está presente desde que a subtração ocorra durante o repouso noturno, ou

seja, quando as pessoas de um modo geral estão menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios, com ou sem moradores no seu interior repousando, o furto merece pena mais severa. É a solução correta, pois sustentar o contrário faz com que a circunstância agravante se concentre no fato de haver maior perigo para a vítima – que está em casa dormindo – quando a subtração se realiza no mesmo local, o que nos parece tenha sido o objetivo da lei. Nessa visão: STJ: “Para a incidência da cuasa especial de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, sendo irrelevante o fato de que o crime tenha sido cometido em estabelecimento fechado” (REsp 1.191.065-MG, 5ª T., rel. Gilson Dipp, 17.04.2012, v.u.).

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. (1) FURTO SIMPLES. REPOUSO NOTURNO MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (2) RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELA VÍTIMA. VALIDADE. (3) TESTEMUNHOS DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. (4) "RES" ENCONTRADA NA POSSE DO RECORRENTE, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (5) RÉU CONFESSO. (6) MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO (7) FURTO CONSUMADO. (8) DOSIMETRIA DA PENA QUE EXIGE REPARO. CERTIDÕES INIDÔNEAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. CONTRADIÇÃO À SÚMULA 444, DO STJ. (9) DESDOBRAMENTO DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA MERECEDORA DE REPARO, SOB O RISCO DE INTERPRETAÇÃO "IN MALAM PARTEM". (10) REGIME SEMIABERTO. (11) DETRAÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO NESTA INSTÂNCIA. (12) PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...) 6.2. Repouso noturno. Não se adota o critério do exato momento em que a vítima estaria dormindo, sob pena de incorrer em demasiada subjetividade e gerar enorme insegurança jurídica. Aliás, o aumento de pena atinente ao repouso noturno justifica-se não somente pela menor intensidade de vigilância por parte da vítima, mas, mormente, em relação à vigilância dada por terceiros. Outrossim, não há que se falar sobre a necessidade do imóvel ser uma residência ou estabelecimento comercial, porquanto o local em que se deu o crime é irrelevante, bastando que ele seja praticado, tão somente, durante o período de repouso noturno. Precedentes do STJ (REsp 1113558/RS - Rel. Min. Jorge Mussi - 5ª T. - j. 17.06.2010 - DJe 28.06.2010 e HC 29.153/MS - Rel. Min. Gilson Dipp - 5ª T. - j. 02.10.2003 - DJe 03.11.2003). (...) 8. Provimento parcial do recurso defensivo. (TJSP - Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Santo André; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 22/11/2016; Data de registro: 24/11/2016).

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça ensina:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TENTATIVA DE FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.642.619 - AM (2016/0323079-0) RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 03/02/2017).

[...] 2.3 INVIABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DISPOSTA NO § 1º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. A defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena descrita no § 1º do art. 155 do Código Penal, sob alegação de que "no momento da ocorrência do suposto furto tanto as vítimas quanto as pessoas presente nas imediações do Hospital e Maternidade Tereza Ramos estariam atentos e vigilantes". Sem razão, veja-se: O crime foi praticado por volta das 02h00min da madrugada, período em que a maioria das pessoas se recolhem para o descanso, fato que caracteriza o repouso noturno. E nessa linha, repisa-se o depoimento judicial do policial militar Maicon, o qual afirmou "que não lembra o horário, mas era de madrugada, bem tarde; [...]"; (mídia eletrônica - fl. 54). Sobre o repouso noturno, Julio Fabriní Mirabete ensina: E agravada a pena de um terço no furto praticado durante o repouso noturno, em que é maior o perigo para o bem jurídico e se oferece melhores oportunidades para a prática do ilícito. Repouso noturno é expressão que não se confunde com noite, mas o período em que, pelos costumes locais, é o tempo entre a hora em que a população se recolhe e a quem desperta para

a vida cotidiana (in Código Penal Interpretado, 1a ed. São Paulo: Atlas, p. 908, grifo nosso). Ainda, oportunas as palavras do doutrinador Cleber Rogério Masson: A causa de aumento de pena inerente ao repouso noturno não se relaciona, obrigatoriamente, com a circunstância de ser o furto cometido em casa habitada. Em verdade, o Código Penal sequer faz distinção se o crime é praticado intra ou extra muros. O maior perigo pessoal proporcionado à vítima não se encontra entre os fundamentos mencionados para o tratamento penal mais severo do furto noturno. Além disso, o furto é crime contra o patrimônio, e não contra a pessoa, e o patrimônio resta mais fragilizado durante o repouso noturno. Destarte, a majorante é perfeitamente aplicável aos furtos cometidos durante o repouso noturno em automóveis estacionados em vias públicas, bem como em estabelecimentos comerciais (Direito Penal esquematizado: parte especial, 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 321, grifo nosso). Destaca-se, outrossim, que para a configuração do repouso noturno, necessária, tão somente, a demonstração de que o crime ocorreu em período no qual a cidade encontra-se recolhida e a maioria da população esteja dormindo, pouco importando tratar-se o bem jurídico violado de residências ou bens móveis. [...] Destarte, estando evidenciado nos autos que o furto ocorreu durante o repouso noturno, mantém-se a referida causa de aumento de pena. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS Nº 322.171 - SC (2015/0094395-1) RELATOR: MINISTRO NEFI CORDEIRO. 01.02.2017).

Nesse sentido, imperioso é reconhecer a causa de aumento da pena.

4) Da escalada

Os furtos cometidos mediante escalada pressupõem destreza por parte de seu agente, motivo pelo qual a conduta dele é apenada mais severamente.

O laudo pericial constatou que o acesso do furtador ao imóvel ocorreu mediante escalada do portão do imóvel nº 348 da Rua Ubatuba, dando acesso aos telhados das casas, com posterior rompimento da cerca elétrica do imóvel nº 184 da Rua Baroneza de Resende (fls. 204/209).

O próprio réu indicou, aos policiais militares que o abordaram, que ingressou na residência pulando o portão que tinha, segundo Jamisson, 1,70m de altura.

Nesse sentido, a prova é suficiente para a certeza da acusação.

A qualificadora, assim, restou confirmada.

5) Do princípio da insignificância

Formulado por Claus Roxin, em seu Política Criminal y sistema del Derecho Penal, o princípio da insignificância se refere àquelas condutas que lesionam minimamente ou causam risco de lesão mínima a um bem jurídico penalmente protegido.

Entende-se que não se justifica a imposição de pena criminal a tais comportamentos que quase nada atingem o bem jurídico, de maneira que se deveria excluir sua tipicidade.

A jurisprudência foi aperfeiçoando a utilização do princípio e definiu os critérios para seu reconhecimento.

Assim, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal se manifestou no seguinte sentido:

"O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: 'DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR'. - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa

lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social”. PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. (STF – 2ª Turma – Rel. Min. Celso de Mello – HC 84.412-SP – v.u. 19.10.2004 – D.J. 19.11.2004).

Assim, sustenta o Tribunal Superior acima que para que se aplique validamente o princípio da insignificância sem gerar insegurança jurídica, necessário que estejam presentes os seguintes requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente; a nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Com isso, não fica o princípio da insignificância restrito ao aspecto quantitativo da lesão causada pelo ato ilícito, mas se amplia para tocar os aspectos sociais e econômicos da própria conduta do agente, além de exigir que se observem as condições pessoais do sujeito ativo do delito.

Pessoa primária, sem antecedentes de monta, de pouca idade, que pratique delito sem violência nem grave ameaça contra a pessoa e que tenha diminutos resultados materiais e socioeconômicos é merecedora da aplicação do princípio da insignificância, afastando-se a tipicidade de seu comportamento.

Se, do contrário, trata-se de pessoa que costumeiramente ataca bens jurídicos alheios, violando o direito de propriedade, a incolumidade pública, entre outros, essa não merece tratamento benéfico, não se